

1500434-87.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, 56 porções de maconha e 29 pedras de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500434-87.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500434-87.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNI HENRIQUE NONATO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

GIOVANNI HENRIQUE NONATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, 56 porções de maconha e 29 pedras de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendida com o acusado a quantia de R\$40,00.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Realizados os debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado, bem como o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, requerendo, outrossim, não seja aplicada a causa de diminuição de pena descrita no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos. Pediu a fixação do regime inicial fechado e, finalmente, o perdimento da quantia apreendida com o réu.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por falta de provas.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pedindo o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, pleiteando, finalmente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse que estava a caminho da padaria para comprar pão, a pedido de sua mãe, e parou para conversar com quatro amigos com quem joga futebol. Alegou que, nesse momento, os policiais aproximaram-se em viatura descaracterizada e os abordaram, mandando que deitassem no chão. Contou que os policiais não encontraram nada em sua posse, mas dirigiram-se ao lado oposto da rua, onde localizaram uma sacola em um muro. Disse que, com o encontro daquela sacola, os policiais o algemaram e algemaram dois de seus amigos, conduzindo-os à delegacia, sendo que outros dois amigos abordados foram liberados ainda no local em que ocorreram os fatos. Alegou que, na delegacia, seus dois amigos foram ouvidos primeiro e foram liberados, tendo sido o único a permanecer detido. Disse não saber a quem pertencia as drogas apreendidas pelos policiais.

Todavia, a negativa do réu e a versão por ele fornecida, além de não serem críveis, não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial civil Caio Antônio Marques Pereira, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que estava em viatura descaracterizada com seu parceiro de ofício, em diligência por local onde reiteradamente ocorre o tráfico de entorpecentes, quando presenciou a venda de drogas realizada pelo acusado. Declarou que viu o réu realizar uma segunda venda de entorpecente e, na terceira vez em que ele efetuaria a transação, conseguiu visualizar o local onde o réu guardava as drogas. Consignou que o acusado mantinha poucas porções em sua posse, armazenando a maior quantidade de drogas em um saco, colocado no buraco de uma parede. Disse que, ao constatar o local onde as drogas eram guardadas, foi realizada a abordagem do acusado. Narrou que foi apreendida a quantia de R\$40,00, que não recordou se estava em posse do réu ou na sacola que estava no buraco do muro, relatando que, nesta sacola apreendida, foram encontrados 19 eppendorfs de cocaína, 29 pedras de crack e 56 porções de maconha. Esclareceu que a campana foi rápida, pois foram surpreendidos pela venda de drogas realizada pelo réu ao passar pelo local em viatura. Disse que, com a viatura parada, realizou o monitoramento, até que viu o acusado efetuar outras duas vendas de drogas, bem como viu o local onde ele armazenava os entorpecentes. Relatou que o réu, informalmente, admitiu a prática do tráfico de drogas. Consignou que não foi possível realizar a abordagem dos indivíduos que adquiriram os entorpecentes com o acusado, pois esta ação poderia comprometer a abordagem e prisão do réu. Esclareceu que a sacola contendo drogas estava encaixada em um buraco em um muro de alvenaria, próximo ao qual estava o acusado. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

Em mesmo sentido, a testemunha policial civil Raphael Ramos Jacovani, ouvida em Juízo, narrou que realizava diligência pelo local dos fatos com seu parceiro Caio quando, ao passar por um conhecido ponto de tráfico de drogas, local em que já efetuaram prisões anteriormente, avistou o acusado em atitude suspeita. Relatou que, estacionada a viatura descaracterizada a certa distância, foi realizada

campana por cerca de vinte minutos, durante os quais presenciou, por duas ou três vezes, uma pessoa aproximar-se do acusado e a ele entregar algo, tendo visto o réu atravessar a rua e, junto a um muro, abaixar-se e pegar algo de uma sacola, retornando até o indivíduo que o aguardava. Realizada a abordagem, o acusado dispensou ao solo uma porção de maconha que tinha em mãos e, em busca pessoal, com ele foram encontrados R\$40,00. Declarou que enquanto realizou a contenção do acusado, seu parceiro Caio foi ao local onde estava a sacola, constatando que nela havia cerca de 12 porções de cocaína, pouco mais de 20 pedras de crack e quase 60 porções de maconha. Narrou que, indagado sobre os fatos, o réu admitiu, informalmente, a prática do tráfico de drogas, dizendo que passava por necessidade. Disse que o local em que se deram os fatos é movimentado e lá havia muitas pessoas que viram a abordagem. Esclareceu que outras pessoas próximas ao acusado também foram abordadas, mas com elas nada foi encontrado. Consignou que os indivíduos que haviam se aproximado do acusado para a compra de drogas saíram do local em direção contrária à da viatura e relatou que não foi possível abordá-las sem prejuízo da continuidade do monitoramento da ação realizada pelo réu. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão das drogas em sua posse e também em depósito.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e

as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo

praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos policiais civis, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes, e encontram-se em verdadeira harmonia com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Os policiais civis forneceram informações detalhadas acerca da diligência policial e da conduta do acusado que puderam visualizar durante a campanha realizada por eles.

Bem relataram as testemunhas policiais terem visto o acusado, em local já conhecido pela reiterada ocorrência de tráfico de drogas, e narraram que, naquela data, presenciaram, mais de uma vez, indivíduos aproximando-se do acusado e dele adquirindo drogas, tendo visto o acusado buscar os entorpecentes em uma sacola junto a um muro.

Veja-se que a testemunha policial Caio ressaltou que viu o réu vender drogas a indivíduos que o procuraram por três vezes, sendo que, durante a última venda que presenciou, viu-o buscar os entorpecentes na sacola que estava armazenada no buraco de um muro. No mesmo sentido, a testemunha Raphael relatou que pode ver a movimentação típica do tráfico de drogas perpetrada pelo réu por duas ou três vezes.

Acrescentou a testemunha Raphael que, no momento da abordagem, o acusado dispensou uma porção de maconha que ele estava portando e, em busca pessoal, encontrou com ele o valor de R\$40,00.

Ainda, ambas as testemunhas asseveraram que, na sacola apreendida no local em que viram o acusado mexer, foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína e crack, frisando, outrossim, que o réu, informalmente, admitiu a prática do crime de tráfico de drogas.

Note-se que os policiais bem puderam identificar o acusado como o indivíduo que estava realizando a venda de entorpecentes, distinguindo-o das demais pessoas que o haviam procurado para comprar as drogas com ele.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não há dúvidas de que era o acusado o indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos e que a ele pertenciam os entorpecentes apreendidos.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada de que estaria no local dos fatos apenas conversando com quatro amigos e que, realizada a abordagem e o encontro de drogas ao lado oposto da rua, somente ele e outros dois amigos foram conduzidos à delegacia, bem como que, em solo policial, estes dois amigos foram liberados e somente ele permaneceu detido, sendo-lhe atribuída falsamente a prática do tráfico de drogas por policiais que sequer o conheciam anteriormente aos fatos não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos policiais civis encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da

quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade, natureza e variedade e das demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310).

Provas, portanto, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu em relação a esse delito é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Diante da natureza e da variedade de drogas apreendidas na posse do acusado, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mas sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se, portanto, o aumento de sua pena-base.

Outrossim, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é portador de Maus Antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 17/18, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR". REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

02. "O período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os Maus Antecedentes" (AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 06/11/2014). 03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art.157 § 2º, inc.II), tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para seu cumprimento inicial (CP, art.33,§ 3º). 04. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 314814 SP 2015/0013862-6, T5 - Quinta Turma, Ministro NEWTON TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC), Julgamento: 19/05/2015, Publicação: DJe 25/05/2015) (grifei). Assim, aumento a pena-base do acusado em 1/3, ficando ela fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto,

o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em 1/6, ficando a pena fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estabelecido.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade da droga apreendida.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

O Superior Tribunal de Justiça assim também já decidiu: "É inaplicável a redução legal ao caso, pois, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, não atende ao requisito previsto no mencionado artigo, uma vez que se dedica a atividades criminosas, pois evidenciada nos autos a prática de tráfico, em razão da grande quantidade de substância entorpecente apreendida (oito papелotes de cocaína e novecentos e sessenta e dois invólucros contendo "crack", além de balança de precisão". (HC 151676 - SP, 6ª T, rel. OG FERNANDES, 10.05.2010, V.U).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS A DENOTAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Corte de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343 /2006 por entender que o paciente dedicava-se às atividades criminosas, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas - 305 invólucros plásticos contendo 155,8 g de cocaína, bem como 264 invólucros de plástico contendo 78,7 g de crack - (art. 42 da Lei n.º 11.343 /2006). Escorreito o afastamento da benesse, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343 /06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44

do Código Penal , segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. In casu, tendo a reprimenda final alcançado 5 anos de reclusão, não é possível a pretendida substituição. 3. Devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, diante da considerável quantidade e da variedade de drogas a denotar dedicação às atividades criminosas, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - Habeas Corpus 311718 SP 2014/0330976-6 Data de publicação: 09/03/2015)

Assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Ementa: Apelação Tráfico de entorpecente - Autoria e materialidade configuradas. Pena bem aplicada. Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a quantidade apreendida e demais circunstâncias da conduta. Regime fechado e inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Precedentes. Recurso desprovido". (Apelação nº 3006691-38.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator IVAN SARTORI)

Ressalte-se, outrossim, que o acusado ostenta maus antecedentes em razão da prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outro processo por este mesmo delito (fls. 18), elementos estes que somados à quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a

respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GIOVANNI HENRIQUE NONATO, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a quantidade, a natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 30 de março de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA